

ג' אדר א, תשפ"ד
12 בפברואר 2024

לכבוד
ח"כ שמחה רוטמן
יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט

שלום רב,

**הנדון: עמדת הסניגוריה הציבורית להצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – הזדהות עם מבצע עבירת
טרור מסוג המתה), התשפ"ג-2023**

הצעת החוק שבנדון מבקשת להרחיב באופן ניכר את עבירת ההסתה לטרור הקבועה בסעיף 24(ב) לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016, אשר דינה 5 שנות מאסר, כדלקמן:

1. ביטול מוחלט של המבחן ההסתברותי הקבוע כיום בחלופה השנייה לעבירת ההסתה ("מפרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו, ועל פי תוכנו של הפרסום והנסיבות שבהן פורסם יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה טרור");
2. הרחבת עבירה זו שעניינה דברי שבח, אהדה או עידוד גם "למבצע עבירה לפי 300, 301 או 305 לחוק העונשין [עבירות רצח וניסיון לרצח] המהווה עבירת טרור".

בראשית הדברים יודגש כי אין חולק על הצורך הביטחוני העומד ביסוד הצעת החוק, במיוחד בימי לחימה ולמול מעשי הטרור הנפשעים כנגד אזרחי ואזרחיות ישראל, בפרט מאז ה-7 באוקטובר. אך דווקא בעת הזו, יש להקפיד ולשמור אף יותר מתמיד על עקרונות היסוד של המשפט הפלילי, להימנע מפגיעה עודפת בזכויות ובחירויות חוקתיות וכן להיזהר מפני הפללת יתר של אוכלוסיות נורמטיביות.

לפיכך, הסניגוריה הציבורית מתנגדת עקרונית להצעת החוק, מן הסיבות שלהלן:

בראש ובראשונה, אנו רואים בעייתיות מיוחדת בהצעה האמורה למחוק את הסיפא של סעיף 24(ב)(2), וכך לבטל את הדרישה הקיימת למבחן הסתברותי לאפשרות ביצוע מעשה טרור. זאת, בניגוד למרבית עבירות הביטוי הקבועות בחוק הפלילי הישראלי (אף בסעיפים אחרים בחוק המאבק בטרור), וכן בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון אשר לאורך השנים הוסיפה מבחן הסתברותי לעניין פרשנותם של איסורי ביטוי.

יודגש כי כבר כיום בנוסחה המקורי, עבירת ההסתה לפי סעיף 24(ב)(2) לחוק מאופיינת בעמימות רבה ומנוסחת בהרחבה יתרה. בין השאר, לא מופיע בה כל יסוד נפשי מיוחד של כוונה או מטרה הנובעת מדברי האדם, כפי שראוי ונהוג לעשות בעבירות ביטוי, ואף לא דרישה הסתברותית מחמירה ל"וודאות קרובה" של התממשות הסיכון. כל שקבוע בסעיף הוא מבחן הסתברותי רחב של "אפשרות ממשית" כי הפרסום יביא לעשיית מעשה טרור. לעניין זה יש להזכיר כי החלופה השנייה בעבירת ההסתה אינה עוסקת בקריאות ישירות לביצוע מעשי טרור (אלו מוסדרות בחלופה הראשונה של הסעיף ואינן דורשות מבחן הסתברותי). לטעמנו, איסור תוכני אשר אינו מותנה בקיומו של מבחן הסתברותי (וכאמור אף לא

ביסוד נפשי מיוחד של כוונה או מטרה) עלול לפגוע בזכות החוקתית לחופש הביטוי ומעורר קשיים חוקתיים של ממש.

היבט מרכזי נוסף בהקשר לכך, הוא הגברת הסיכון לאכיפה סלקטיבית ושרירותית. מלבד הבעייתיות החוקתית הברורה באכיפה בלתי שוויונית, היבט זה אף עלול להוביל לעומס רב על מערכת אכיפת החוק ולהפוך את האכיפה לבלתי יעילה ובלתי ממוקדת, ובסופו של דבר לפגוע במטרת החוק. **התיקון המוצע צפוי להביא, קרוב וודאי, להפלת יתר של אוכלוסיות רחבות** (לרבות אוכלוסיות נורמטיביות) שכן הוא מעמיד בסכנת הפללה גם פרסומים מינוריים מבחינת תוכנם או פוטנציאל ההשפעה שלהם.

עוד יוער כי ביטול הדרישה למבחן הסתברותי מעבירת ההסתה בסעיף 24(ב) יוביל לבלבול ולחוסר הרמוניה בין סעיפי החוק, ובפרט אל מול העבירות של הזדהות עם ארגון טרור הקבועות בסעיף 24(א) לחוק. על פניו, מצב הדברים החדש יוביל ליצירת מספר עבירות שאינן קוהרנטיות מבחינת הרף הראייתי והעונשי, ומנגד הלכה למעשה במידה רבה יחפפו זו לזו וייבלעו זו בזו. הדבר יוביל להעברת מרכז הכוח מהכנסת ומבתי המשפט לרשויות התביעה, ובכך כשלעצמו יהווה כר פורה לאכיפה ברחיקנית ושרירותית.

באשר למרכיב השני בהצעת החוק, שלפיו בד ובד עם ביטול הדרישה למבחן ההסתברותי, יורחב עד מאד היקף תחולתה של עבירת ההסתה, כך שלצד האיסור על "דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור", יתווסף "או מבצע עבירת טרור לפי סעיפים 300, 301א', או 305": ראשית יצוין כי במקרים רבים, הלכה למעשה, ממילא דברי שבח ואהדה למבצעי טרור ממילא יכללו בתוכם את מעשה הטרור עצמו – ולכן כבר ניתן לכך מענה בחוק הקיים. ואולם, **לטעמנו קיים חשש של ממש להפליל פרסומים כאמור שאין להם כל קשר או זיקה לעשיית מעשה טרור, אפילו אם הם מקוממים ומרגיזים.** הכנסת התוספת המוצעת לסעיף החוק בשילוב עם ביטול המבחן ההסתברותי, תוביל למצבים אבסורדיים בהם כל אזכור (אף אם נאמר למשל כביטוי אבלות על מותו של בן משפחה או מכר), עלול להביא אדם נורמטיבי להסתבכות בפלילים ולייחס לו עבירת טרור, על כל המשתמע מכך.

לסיום נזכיר כי בתקופה מתוחה זו מדיניות האכיפה כלפי ביטויי הזדהות עם טרור וההסתה לטרור החמירה פי עשרות מונים מבימי שגרה. על פי מדיניות זו, **בימים אלו נכנסים תחת עבירות אלו מעשים שבעבר לא היו נאכפים ויתכן שאף לא היו נחשבים לעבירה פלילית בימים כתיקונם**, לרבות פרסומים בודדים, שיתוף עם חשיפה מינימאלית ברשת חברתית וכן התבטאויות גבוליות ביותר מבחינת חומרתן. על כן, הניסיון מלמד כי לרשויות האכיפה קיימים כלים מספקים ורחבים, לרבות בחקיקה הקיימת, כדי להתמודד עם תופעות של הזדהות והסתה לטרור.

לאור כל האמור, אנו נמליץ לוועדה להימנע מקידומה של הצעת החוק.

בכבוד רב ובברכה,

ישי שרון, עו"ד

מנהל מחלקת חקיקה, ומדיניות

הסניגוריה הציבורית הארצית